知识产权法学

授课：李国英

学院：南京师范大学法学院

作者：左妍

时间：2024 年秋学期

目录

第一章 知识产权法总论 4
第一节 前言 4
一、 知识经济时代 ——知识产权法的时代 4
二、 国家知识产权战略 5
第二章 总 论 6
第一节 知识产权概述 6
一、 知识产权的概念与范围 6
二、 知识产权的性质与特征 7
三、 知识产权的主体 7
四、 知识产权的客体 8
五、 知识产权的保护? 9
第二节 知识产权法概述 9
一、 知识产权法概念 9
二、 知识产权法的历史变迁 9
三、 知识产权法的法律地位 9
四、 知识产权法的体系 9
第三节 知识产权国际保护制度概述 10
一、 知识产权国际保护制度的成因 10
二、 知识产权国际保护制度的主要原则 10
三、 知识产权国际保护制度的历史分期 10
四、 现行知识产权国际组织及其管理下的主要知识产权国际公约 10
第三章 著作权法 11
第一节 著作权概述 11
一、 著作权的概念与性质 11
二、 著作权与相关权利的区别 11
三、 著作权制度的产生与发展 11
四、 我国著作权法的主要原则 13
第二节 著作权的客体 13
一、 著作权法保护的作品 14
二、 民间文学艺术作品的保护 15
三、 计算机软件的保护 15
四、 著作权客体的排除领域 15
第三节 著作权的内容 15
一、 著作人身权 15
二、 著作财产权 16
第四节 著作权的主体 18
（一）著作权主体的概念与分类 18
（二）著作权的原始主体——作者 18
（三）著作权的继受主体——其他著作权人 19
（四）特殊作品的著作权主体! 19
第五节 相关权利 22
一、 相关权概述 22

二、 出版者权 22
三、 表演者权 23
四、 录音录像制作者权 23
五、 广播组织权 24
第六节 著作权的利用 25
一、 著作权的转让 25
二、 著作权的许可使用 25
三、 著作权的其他利用 25
第七节 著作权的限制 25
一、 合理使用 25
二、 法定许可使用 26
三、 强制许可使用 27
四、 著作权的穷竭 27
第八节 著作权的保护 29
第四章 专利权 31
一、 专利制度概述 31
二、 专利权的客体 32
三、 专利权的主体及权利归属 36
四、 专利权的取得 37
五、 专利权的期限、终止与无效 40
六、 专利权的内容、限制与特别许可 41
七、 专利权的保护 43
第五章 商标法 47
一、 商标与商标权 47
二、 商标注册 50
三、 商标评审 55
四、 商标权的行使 55
五、 商标管理 57
六、 商标权的保护 57
七、 驰名商标的特别保护 59
八、 补充：商标权的限制问题 62

第一章 知识产权法总论

第一节 前言

一、知识经济时代 ——知识产权法的时代

三种经济形态：
劳力经济（农业经济）
资源经济（工业经济）

★ 知识经济（后工业经济）：一种以知识和信息的生产、分配、传播和使用为基础，以创造性的人力资源为依托，以高科技产业和智力产业为支柱的全新的经济形态。

- 知识经济的特点：
  知识经济是一种信息化经济
  知识经济是一种网络化经济
  知识经济是一种创新型经济
  知识经济是一种智力支撑型经济
  知识经济是一种可持续发展型经济
- 知识产权法对发展知识经济的作用：
  激励知识创造
  有效配置资源
  促进发明创造者将其技术成果尽快地转化为生产力
  保护技术市场公平有序的竞争

知识产权保护的合理性分析

西方三股反知识产权思潮：

- “知识产权怀疑论”——以美国学者 Anatoly Volynets 为代表,对知识产权制度提出了十大疑问,认为现在的知识产权保护不是对社会、经济、文化、科技等产生了促进作用，而是相反地产生了障碍效应。
- “知识产权废除论”——以美国学者 Richard Stallman 为代表，提出了限制甚至废除知识产权制度的主张,引起了强烈的社会反响，形成了一股反知识产权思潮。
- “知识产权僵化论”——以加拿大学者 Daniel J. Gervais 为代表,在研究传统知识保护过程中,认为现在的知识产权制度过于僵化,难以适应现实社会的客观需要,应当对现行知识产权制度进行改造。

（一）劳动财产权学说（劳动论）——脱离自然共有状态，留有足够同样好的东西给别人，取得财产权。只能作为理由之一进行解释。

“土地和一切低等动物为人类所共有，但是每一个人对他自己的人身享有一种所有权，除他之外任何人都没有这种权利。他的身体所从事的劳动和他的双手所进行的工作，我们可以说是正当地属于他的。所以只要他使任何东西脱离自然所提供的和那个东西所处的状态，他就已经渗进他的劳动，在这上面掺加他自己的某些东西，因而使它成为他的财产。……至

少在还留有足够的、同样好的东西给其他共有人的情况下，事情就是如此。”

——《政府论》下篇，商务印书馆 1964 年版，第 53 页

（二）自由意志理论（人格论）——自由意志理论，也叫人格理论，意志体现在物的所有上，成为私有财产。

“人有权把他的意志体现在任何物中，因而使该物成为我的东西”，“我的意志，作为人的意志，并且是作为一个单个的意志，在财产中我的目的，财产获得了私有财产的性质。”

——黑格尔《法哲学原理》商务印书馆 1961 年版，第 52 页

（三）激励理论（功利论）——功利理论，看知识产权化是否给社会带来福祉。但激励也要实现利益平衡，避免过度保护。

亚当·斯密：衡量一种行为的功过，“要看情感计划和趋于产生的结果是有益还是有害”。

——[英]亚当·斯密：《道德情操论》，余涌译，中国社会科学出版社 2003 年版，第 71 页

杰里米·边沁：“它按照看来势必增大或减小利益有关者之幸福的倾向，亦即是促进或妨碍此种幸福的倾向，来赞成或非难任何一项行动。”这就是我们熟知是“幸福最大化原理”

—— [英]边沁：《道德与立法原理导论》，时殷弘译，商务印书馆 2000 年版，第 58 页

（四）社会规划论（综合论）

- 社会规划论的主张：包括著作权、商标权和专利权等在内的知识产权能够而且应当加以架构，不但因为他们为社会带来的知识产品会使人们达致一种优良的生活，而且在于它们自身的架构会成为够构筑理想社会的要素，从而把人们带入到一个公正的、有吸引力的理想社会中去。（强调知识产权的政治性质和政治功能，甚至呼吁建立知识产权政治学。）
- 费舍尔和知识产权的乌托邦范式：吸取功利主义与自由主义的合理成分，构建一种优良社会或乌托邦社会：文化多样性、丰富的艺术传统、充分的自我感和感应能力、设计精巧的经济制度、广泛而公共的必修教育以及平等。
- 奈特尼尔和知识产权的民主范式：著作权有两项功能：生产功能和结构功能，通过这两项功能来促成一个民主的市民社会。

二、国家知识产权战略

1.《国家知识产权战略纲要》（国发〔2008〕18 号）

2.《知识产权强国建设纲要》（2021-2035 年）

第二章 总　论

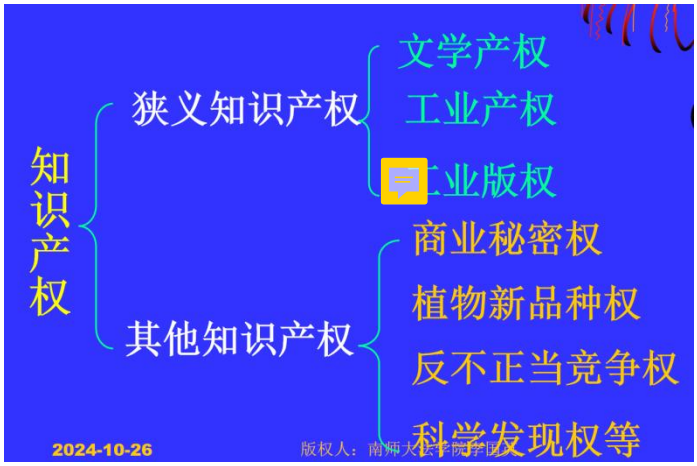
第一节 知识产权概述

一、知识产权的概念与范围

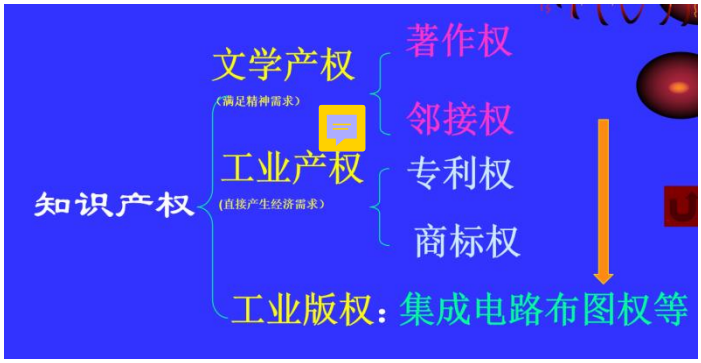
（一）概念：知识产权是民事主体直接支配特定的智力成果或商业标识，并享受其利益的排他性的民事权利。

（二）范围

- 广义的知识产权



- 狭义的知识产权



二、知识产权的性质与特征

（一）知识产权的性质

1.双重属性（课后阅读：李琛的《质疑知识产权之人身财产一体性》）
2.私权属性（讨论：私权的公权化问题）
3.公权属性（《公约》）
4.政策工具性（国家知识产权战略）

（二）知识产权的特征（三要件——吴汉东）

- 专有性

表现为合法垄断+市场独占+法律的专有授权。特点为信息公开、权利独占、排斥一切人对知识产品的不法利用。不是指排他性，而是某类同样的客体即知识产品只有一个知识产权，归某个特定权利人享有，而物权则是每个产品都有一个所有权人。

- 地域性：效力仅限于本国境内
- 时间性：仅在法律规定的期限内保护，超期自行消灭同时为全人类共享
- 客体的非物质性：知识产权特征的本质，即

1）不发生有体控制的占有
2）不发生有体损耗的使用
3）不发生消灭知识产品的事实处分与有形交付的法律处分，导致非权利人有可能处分属于他人而自己并未占有的知识产品

三、知识产权的主体

（一）概念和范围

- 自然人：6 岁小孩对自己的绘画作品是否享有著作权
- 法人
- 其他组织

（二）主体制度的特征

1.知识产权的原始取得:以创造者的身份为基础，以国家认可或授予为条件。
2.知识产权的继受取得:往往是不完全取得或限制取得

- 注意：

1）发生继受取得的只能是财产权，不能是人身权
2）不完全转让只能在约定的财产权项上享有利益
3）若干受让人只能在各自有效区域内行使权利
3.知识产权法对外国人的主体资格:主要奉行“有条件的国民待遇原则”，以别于一般财产法

所采取“有限制的国民待遇原则”。？有条件/有限制的国民待遇原则的区别

- 有条件的国民待遇原则是指在一些特定条件下，东道国对外国自然人、法人提供不同于无条件国民待遇的待遇标准。这种待遇可以是有限的或附加条件的，具体条件可能包括在东道国的住所、营业所、国际公约的成员资格等。
- 有限制的国民待遇原则是指在某些条件下，对外国人或外国企业给予的待遇有所限制，以确保国家的主权和安全不受侵害。

Q：知识产权是法律授予的还是天生具有的？

A：著作权天生具有，但是因为客体的非物质性，需要国家保障权利的行使。专利权是授予的。

四、知识产权的客体

（一）知识产品的概念

知识产品：是人们在科学、技术、文化等精神领域所创造的产品，它是与物质产品（有体物）相区别而独立存在的客体范畴。

（二）知识产品的类别

创造性成果——包括作品及其传播媒介、工业技术。

经营性标记——包括商标、商号、产地标记、其他与制止不正当竞争有关的识别性标记等。

经营性资信——包括特许经营、信用、商誉等 。

（三）知识产品的基本特点

- 知识产品的特点（吴汉东）：

创造性：是知识产品取得法律保护的条件。不同知识产品对创造性程度的要求不一样。

非物质性 ：不具有一定形态，不占有一定空间，人们对它的“占有”表现为认识和利用。

公开性：是所有人取得知识产权的前提。知识是公开的，权利是垄断的。

社会性

- 知识的特点：

知识不具有实体性不能独立存在

知识在时间上具有永存性

知识在空间上具有可复制性

- 智力成果和商业标记的特点：

无形性

可复制性

公共性

永存性

五、知识产权的保护？

（一）保护范围

（二）侵犯知识产权行为的基本特征

（三）侵犯知识产权行为的归责原则——过错责任原则？

- 讨论：过错 or 无过错责任原则？

侵权法上有过错才承担赔偿责任，因此归责原则仅指赔偿之责，物权请求权停止侵害等是后期加入的，属于权利效力。知识产权适用过错推定原则。

（四）侵犯知识产权行为的法律救济

第二节 知识产权法概述

一、知识产权法概念

知识产权法是调整因知识产品而产生的各种社会关系的法律规范的总和，它是国际上通行的确认、保护和利用著作权、工业产权以及其他智力成果专有权利的专门法律制度。

二、知识产权法的历史变迁

三、知识产权法的法律地位

知识产权基本法应该是以公法为主旨的综合性法律规范体系。具有私法属性，又有综合性规范的特征。

四、知识产权法的体系

著作权法律制度
专利权法律制度
工业版权法律制度
商标权法律制度
商号权法律制度
产地标记权法律制度

商业秘密权法律制度
反不正当竞争法律制度

第三节 知识产权国际保护制度概述

一、知识产权国际保护制度的成因

1、国际经济贸易的发展与知识产权地域性限制的克服
2、知识产权保护的国际协调与国内法单独体系的改变

二、知识产权国际保护制度的主要原则

1.国民待遇原则（TRIPS 第三条）
2.最低保护原则
E.g.本国对缔约国国民保护不低于条约规定的最低标准
3. 公共利益原则
E.g.保持公共利益与私人权利利益平衡

三、知识产权国际保护制度的历史分期

1、巴黎联盟与伯尔尼联盟时期
——知识产权国际保护制度的形成
2、世界知识产权组织时期
——知识产权国际保护制度的发展
3、世界贸易组织时期
——知识产权国际保护制度的变革

四、现行知识产权国际组织及其管理下的主要知识产权国际公约

《巴黎公约》《伯尔尼公约》《知识产权协定》

第三章 著作权法

第一节 著作权概述

一、著作权的概念与性质

（一）著作权的概念及其演变

著作权，又称版权，是指作者及其他著作权人对文学、艺术、科学作品所享有的专有性人身权利和财产权利的总称。

- 著作权如何取得：自动取得，“创作主义原则”，直接完成了产生文学、艺术和科学作品，不论是否发表，作者均享有著作权。

（二）著作权的特点

著作人身权的特点：	**著作财产权的特点：**
A、不可转让性	**A、可转让性**
B、不可剥夺性	**B、可剥夺性**
C、不可继承性	**C、可继承性**
D、永久性	**D、期限性**

二、著作权与相关权利的区别

A、著作权与所有权
B、著作权与专利权
C、著作权与商标权

三、著作权制度的产生与发展

（一）西方著作权制度的起源与发展

1.四阶段说：
特许出版时期
著作财产权时期
作者权时期
国际化时期
印刷术技术的发展
录音录像等复制机器的产生

因特网和数字技术的发展
2.三次浪潮理论：
印刷术技术的发展
录音录像等复制机器的产生
因特网和数字技术的发展

（二）我国著作权制度的起源与发展

1.古代：特许制度
2.清末：1910 年《大清著作权律》
3.民国：1928 年《中华民国著作权法》、1930 年《出版法》
4.1949—1991 年：行政法规与规章
5.1991 年《中华人民共和国著作权法》及其三次修改：2001 修改、2010 修改、2021 修改

- 2010 修改：

原第四条：依法禁止出版、传播的作品，不受本法保护（讨论）著作权人行使著作权，不得违反宪法和法律，不得损害公共利益
→第四条：著作权人和与著作权有关的权利人行使权利，不得违反宪法和法律，不得损害公共利益。国家对作品的出版、传播依法进行监督管理。

- 2021 修改（王迁论文）

权利客体：作品概念和类型
权利内容：复制权、修改权、广播权和信息网络传播权
权利归属：视听作品、合作作品、特殊职务作品
权利限制：合理使用和法定许可
邻接权：表演者的出租权、职务表演及权利归属、录音制作者对传播录音制品的获酬权、广播组织的转播权和信息网络传播权
著作权的保护：权利归属与权利存在的推定（第 12 条第 1 款）、诉讼中的举证责任（增加第 56 条第 2 款）、摄影作品保护期的修改
6.我国参加的保护著作权国际公约
1980 年加入《成立世界知识产权组织公约》
1992 年加入《伯尔尼公约》
1992 年加入《世界版权公约》
1993 加入《保护录音制品制作者防止未经许可复制其制品公约》（《唱片公约》）
2001 年加入《与贸易有关的知识产权协定》
2012 缔结《视听表演北京条约》（2020 年 4 月 28 日生效

（三）现代著作权制度的发展趋势

1.著作权内容不断增加，与著作权有关的权利制度陆续出现
2.著作权的保护范围不断扩大
3.国际著作权保护制度体系化
4.两大法系著作权立法差异逐步缩小

（四）网络数字技术对著作权法的挑战

1.著作权的新特点
数字形式成为作品的主要表现形式
作品的归属复杂化，“改编文化”已经抬头
复制和发行的方式发生了改变
出现了集体管理、收费装置、电子交易等新的权利处理机制
2.带来的冲击：
失控（under enforcement）
过渡控制（over control）

四、我国著作权法的主要原则

A、保护作者权益原则

B、传播优秀作品原则

C、作者与公众利益协调一致原则

D、与国际接轨原则

第二节 著作权的客体

- 关于著作权客体的讨论

1、作品标题、角色等元素的可版权性问题（葫芦娃案、《大头儿子小头爸爸》案）
2、手机短信息、微博、博客、日记、书信、广告设计和广告词、电话号码本等的可版权性问题（区分美术作品与文学作品——双重作品）
3、电视节目板式的可版权性问题（已成为表达）
4、体育赛事直播画面和游戏直播画面的可版权性问题（玩游戏的：不算版权，都是开发者开发预设好的）
5、字体和字库、数据和数据库的可版权性问题（北大方正诉暴雪公司）
6、AI 生成内容的可版权性问题（菲林案、Dreamwriter 案）

一、著作权法保护的作品

（一）作品

第三条 本法所称的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。

（二）构成：

1.创作主体：是否仅限自然人？
2.文学、艺术、科学领域的智力成果
3.具有独创性（脸谱案）
4.可复制性(可表现性）

（三）作品受保护的内容：二分法原则

第一，基本含义：即是著作权保护不能延伸到作品中包含或体现的思想，而只能延伸到作品中这些思想的特定表达。二分法原则的确立是限制著作权保护范围的一个重要制度。它在提供创造的激励与留存新创造的原材料之间实现了平衡。：

第二，相关立法

第三，“思想”与“表达”的界定

在这种历史语境中（英国 18 世纪中期开始的大辩论）

“思想”的两层含义：一是指作品中的公有领域部分；二是指作品中反映出的作者的思想和情感。

“表达”的两层含义：一是指作品中作者的个性烙印，是受作者控制的私人部分；二是指作者的思想与情感得以表达的文字形式，即作者将思想见诸文字形式的方法。

有学者将思想分成以下三种基本类型：一是有想象力的概念，它引起了作品的产生，这一层面的思想具有较高程度的抽象性；二是使一部作品有益的原则或者方法，这在功能性作品方面表现得最为突出；三是一些因素，如情节、主题和单个的单词。其中，创作作品的基本建筑材料是最基本的因素。

另有学者认为,“思想”和“表达”不应作语义学上的解释，而应当把它们各自作为作品中“不受保护的部分”和“受保护部分”的隐喻。

第四，二分法的合并或例外

含义：又称思想表达识别的例外原则，它只存在于特定的表达形式中，即表达与思想难以区分，甚至必须被认为混合在思想中，尽管在理论上将其从思想中区分是可能的。在这种情况下，即便表达具有独创性，该作品也不受著作权保护。这种情况即是思想与表达被合并而使得作品作为一个整体不再受著作权保护。

判例：在美国的蜜蜂造型的珠宝著作权侵权案件中，原告主张对蜜蜂造型的珠宝作为一个雕塑作品予以保护，被美国第九巡回法院驳回。法院认为，由于雕塑蜜蜂的思想只有有限的几种表达形式，给予其著作权保护将会在效果上赋予其对这种思想的垄断权。关于蜜蜂的抽象思想和那个蜜蜂造型珠宝的抽象思想智力上的差距是很小的，因为珠宝一般是根据物质或者动物的形状来设计的。由于蜜蜂造型的珠宝的表达形式很有限，特定的珠宝设计不足以给

予著作权保护。
4、作品的分类：
（1）文字作品；
（2）口述作品；
（3）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；
（4）美术、建筑作品；
（5）摄影作品
（6）视听作品（电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；）
（7）工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；
（8）计算机软件；
（9）符合作品特征的其他智力成果。

二、民间文学艺术作品的保护

概念：是指由某社会群体（如民族、区域、国家）在长期的历史过程中创作出来并世代相传、集体使用的歌谣、音乐、戏剧、故事、舞蹈、建筑等作品。

- 可以接受委托：看其是否有合同，可以是本单位的，也可以是其他单位的

三、计算机软件的保护

四、著作权客体的排除领域

第五条：本法不适用于：
（一）法律、法规，国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件，及其官方正式译文；
（二）单纯事实消息（讨论）；
（三）历法、通用数表、通用表格和公式。

第三节 著作权的内容

一、著作人身权

1.发表权：决定作品是否公之于众的权利（展览权、首次传播）
①作品发表是一种权利行使
②向不特定人公开叫发表，不以人数多少为标准
③发表权一次用尽
④未明确不发表，死亡后可由权利人发表；未发表就转让，推定同意发表
⑤发表权行使要让位于思想表现自由

2.署名权：表明作者身份，在作品上署名的权利。

3.修改权：修改或者授权他人修改作品的权利，对作品内容局部变更及文字内容的修改。
授权或依法由他人行使修改权：
①图书、期刊做文字性修改
②摄制电影视为允许必要改动
③报刊转载可以修改
④合作作品修改应合作者协商一致

4.保护作品完整权：保护作品不受歪曲、篡改。（保护思想表达，以免损害声誉）

二、著作财产权

1.复制权（改）：以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻版、数字化等方式将作品制成一份或者多份的权利。
- （1）构成要件：

①以物化方式再现作品
②以物化载体固定作品
E.g.对表演的录像，对雕刻物的拍摄

2.发行权：以出售或赠与的方式向公众提供作品原件或复制件的权利。
→转移原件或复制件的所有权。
- 权利穷竭原则，权利人行使了一次即告用尽了有关权利，不能再行使。该原则仅存在于发行权中，也就是只保护首次发行。

3.出租权（改）：有偿许可他人临时使用视听作品、计算机软件的原件或复制件的权利，计算机软件不是出租的主要标的的除外。是一项独立的财产权利。

4.展览权：公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利。（属于公开传播，展览权属于原件所有人享有）

5.表演权：公开表演作品，以及用各种手段公开传播作品的表演的权利。
- 构成要件

①公开的对象是文学艺术作品
②公开的地点必须是公开场所
③公开表演作品的方式包括机械表演权。
包括朗诵、口述、现场表演、机械表演

6.放映权：通过放映机、幻灯机等设备公开再现美术、摄影、视听作品的权利。（不如表演权的传播能力）

7 广播权（改）：以有线或无线方式公开传播或者转播作品，以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播作品的权利。

8.信息网络传播权（改）：以有线或无线方式向公众提供、使公众可以在选定的时间和地点获得作品的权利。（借助互联网）

9.摄制权
10.改编权
11.翻译权
12.汇编权
13.应当由著作权人享有的其他权利

- 收回权：即作品发表后，作者基于正当的理由，以赔偿使用者损失为条件收回已经发表的作品的权利。
- 接触权：即当原件为少数人占有时，作者为了行使某种著作权而享有的接触作品的权利。
- 追续权：

《草案》第 14 条：美术、摄影作品的原件或者文字、音乐作品的手稿首次转让后，作者或者其继承人、受遗赠人对原件或者手稿的所有人通过拍卖方式转售该原件或者手稿所获得的增值部分，享有分享收益的权利。

- 公共借阅权：作者或者其他权利人应版权作品在公益性图书馆被借阅而依法享有的获得补偿金的权利。（著作权、报酬补偿权 or 奖励制度）

著作权	内容	概念
1	发表权	决定作品是否公之于众的权利
2	署名权	表明作者身份，在作品上署名的权利
3	修改权	修改或者授权他人修改作品的权利
4	保护作品完整权	保护作品不受歪曲、篡改的权利
5	复制权	以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍、数字化等方式将作品制作一份或者多份的权利（独立地位存疑）
6	发行权	以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利
7	出租权	有偿许可他人临时使用视听作品、计算机软件的原件或者复制件的权利，计算机软件不是出租的主要标的的除外
8	展览权	公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利
9	表演权	公开表演作品，以及用各种手段公开播送作品的表演的权利
10	放映权	通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、视听作品等的权利
11	广播权	以有线或者无线方式公开传播或者转播作品，以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利，但不包括本款第十二项规定的权利
12	信息网络传播权	以有线或者无线方式向公众提供，使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利
13	摄制权	以摄制视听作品的方法将作品固定在载体上的权利
14	改编权	改变作品，创作出具有独创性的新作品的权利
15	翻译权	将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利
16	汇编权	将作品或者作品的片段通过选择或者编排，汇集成新作品的权利
17	应当由著作权人享有的其他权利	

著作权人可以许可他人行使前款第 5 项至第 17 项规定的权利，并依照约定或者本法有关规定获得报酬。

著作权人可以全部或者部分转让本条第 1 款第 5 项至第 17 项规定的权利，并依照约定或者本法有关规定获得报酬。

第四节 著作权的主体

（一）著作权主体的概念与分类

1.定义：著作权人是指依法对文学、艺术、科学作品享有著作权的人。

2.分类

《著作权法》第九条：著作权人包括：

（一）作者

（二）其他依照本法享有著作权的自然人、法人或者非法人组织。

根据不同标准，著作权主体可作如下分类：

（1）原始主体与继受主体

（2）国内主体与国外主体

（3）完整著作权主体与部分著作权主体

（二）著作权的原始主体——作者

1、作者的基本含义

- 原始主体，是指在作品创作完成后，直接根据法律规定或者合同约定而对作品享有著作权的人。
- 我国的原始主体：自然人创作者、职务作品中的单位（雇主）、委托作品中的出资人（委托人）。

第十一条　著作权属于作者，本法另有规定的除外。

创作作品的自然人是作者。

由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品，法人或者非法人组织视为作者。

第十二条　在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为作者，且该作品上存在相应权利，但有相反证明的除外。

作者等著作权人可以向国家著作权主管部门认定的登记机构办理作品登记。

与著作权有关的权利参照适用前两款规定。

2、作者的资格

（1）自然人作者

作者即创作作品的自然人。

创作是事实行为，没有民事行为能力的限定，任何人都能通过创作活动取得作者身份。6 岁小孩也是作者

（2）法人作者（拟制作者）

由法人主持（以法人名义创作并发表）+代表法人意志创作+由法人承担责任

3、作者身份的推定

第十二条第一款 在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为作者，且该作品上存在相应权利，但有相反证明的除外。

- 作品版权登记只是证明权利归属的“初步证据”，可以提出相反证明、多种证明形式来证明作者身份。只要假名能连结到真人，也可以视为作者。权利转让、保护期届满则视为不存在相应权利。

4、作者是著作权的原始主体

（三）著作权的继受主体——其他著作权人

继受主体，是指通过转让、继承、受赠或法律规定的其他方式取得全部或者部分著作权的人。只能获得著作财产权。

（四）特殊作品的著作权主体！

1、演绎作品的权利主体

第十三条：改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有，但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权。

- 涉及的问题：

①改编私有作品要获得授权许可；
②第三人应取得双方同意；
③不得歪曲原作；
④著作权归演绎作者；
⑤非法演绎也有著作权

2、合作作品的权利主体

第十四条：两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人，不能成为合作作者。

合作作品的著作权由合作作者通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。

合作作品可以分割使用的，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权，但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。？

（1）合作作品的构成要件：
①合作作者间有共同创作的合意
②合作作品有共同创作行为
（2）涉及的问题：
①涉及开发软件，可以由合作者订立书面合同约定著作权归属
②无论是否分割使用，任一作者都不能阻止作品许可使用，并只能协商一致时行使转让权。
③权利受侵害时，任何作者都可以单独提起诉讼，其他人为必要共同原告。
④其一作者死亡而无人继承、遗赠，其权利由其他合作作者享有。
⑤合作作品 or 演绎作品？看事前同意还是事后认可。

3、汇编作品的权利主体

第十五条：汇编若干作品、作品的片断或者不构成作品的数据或者其他材料，对其内容的选择或者编排上体现独创性的作品，为汇编作品，其著作权由汇编人享有，但行使著作权时，不得侵犯原作品的著作权。

第十六条（加）：使用改编、翻译、注释、整理、汇编已有作品而产生的作品进行出版、演出和制作录音录像制品，应当取得该作品的著作权人和原作品的著作权人许可，并支付报酬。

- 汇编作品 v. 改编作品：

①独创性表现在：汇编元素选择、编排\表现形式的改变

②权利指向对象：对汇编作品的权利不及于原作品片段\演绎作者行使著作权要取得原作者的认可

- 汇编作品 v. 合作作品：

①当事人合意内容不同：他人授权汇编人的合意\共同创作的合意

②创作成果表现形态：汇编作品片段可分割\合作作品有的不可分割

③发表名义：汇编人名义\共同名义共有影视作品的权利主体

4、视听作品的权利主体

第十七条：视听作品中的电影、电视剧作品的著作权由制作者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制作者签订的合同获得报酬。

前款规定以外的视听作品的著作权归属由当事人约定；没有约定或者约定不明确的，由制作者享有，但作者享有署名权和获得报酬的权利

视听作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。

（1）权利归属：著作权全部或部分不归属作者

①著作权归于制作者，制作者是视听作品的决策者、责任承担者，而视听作品的作者是诸如编剧、导演等等的创作者（如演员有创作贡献也可视为作者）。

②视听作品视为合作作品，不论权力来源，制作者享有权利。

（2）涉及的问题：

①制作者行使整体权利

②创作者行使署名权和获得报酬的权利

③著作财产权的确定

④改编摄制的视为演绎作品而非原创作品

⑤视听作品中可以单独使用的作品由其作者单独行使权利

5、职务作品的权利主体

- 职务作品：约定不明的财产权对单位有利解释，人身权对员工有利解释。

第十八条第一款（一般职务作品）：自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品是职务作品，除本条第二款的规定以外，著作权由作者享有，但法人或者非法人组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人与单位使用的相同方式使用该作品。

第十八条第二款（特殊职务作品）：有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人或者非法人组织可以给予作者奖励：

（一）主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品；

（二）报社、期刊社、通讯社、广播电台、电视台的工作人员创作的职务作品；

（三）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。

- 要件：

（1）创作者和单位之间有劳动人事关系
（2）创作作品是该职工的本职工作
（3）创作被动性
（4）意志性（体现自己意志）

- 法人作品 vs 职务作品 vs 委托作品

（1）职务作品 v. 法人作品
根本区别在于作品的创作名义和意志体现
（2）职务作品 v. 委托作品
职务作品以劳动合同关系为基础，是体现自己意志而完成工作任务的创作，由法律直接规定著作权归属；委托作品以委托合同为基础，为完成委托事项而创作，通过合同约定著作权归属。

6、委托作品的权利主体
第十九条：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

- 涉及的问题：

①能否约定著作人身权的归属？无约定则属受托人
②委托人可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品。

7、美术作品的权利主体
第二十条：作品原件所有权的转移，不改变作品著作权的归属，但美术、摄影作品原件的展览权由原件所有人享有。
作者将未发表的美术、摄影作品的原件所有权转让给他人，受让人展览该原件不构成对作者发表权的侵犯。

- 涉及的问题：

①所有人可以处分原件，不影响著作权人行使权利。
②著作权中的展览权一直由原件所有人享有。
③著作权人可以展览复制件。

8、匿名作品的权利主体
《著作权法实施条例》第十三条规定：作者身份不明的作品，由作品原件的所有人行使除署名权以外的著作权。作者身份确定后，由作者或者其继承人行使著作权。

- 涉及的问题：

①未署名也能证实身份的作者不属于匿名情况
②署名权始终属于作者
③原件所有人在匿名作品匿名期间的经济利益有保障

9、民间文学艺术作品的权利主体

10、计算机软件作品的权利主体

【孤儿作品】
含义：著作权人不明

外国人的著作权主体资格

第五节 相关权利

一、相关权概述

（一）相关权的概念

相关权（邻接权），亦称作品传播者权，是指作品的传播者在传播作品的过程中对其创造性劳动成果依法享有的专有权利。

（二）相关权与著作权的关系

	相邻权	著作权
主体不同	帮助作者传播作品的人	作品创作者、依法取得著作权的人
保护对象不同	客体有表演活动、录像制品、电视节目	客体可统称为作品
内容不同	除表演者有形象不受歪曲的人身权，录音录像制作者与广播组织者都不享有人身权	著作权人享有人身权和财产权
保护期限不同	表演后、制作品首次完成起 50 年	作者终生及死后 50 年

（三）相关权制度的产生与发展

二、出版者权

（一）概念：出版者权是指出版者对其出版的作品所享有的一系列权利的总称。

（二）权利内容：版式设计权（第 37 条）

出版者有权许可或者禁止他人使用其出版的图书、期刊的版式设计。

前款规定的权利的保护期为十年，截止于使用该版式设计的图书、期刊首次出版后第十年的 12 月 31 日。

——第 37 条

讨论：专有出版权是著作权 or 相关权？吴：著作权。

（三）出版者的义务？

三、表演者权

（一）概念：表演者权是表演者依法对其表演所享有的权利。

（二）表演者的权利（第 39 条）

第三十九条　表演者对其表演享有下列权利：
（一）表明表演者身份；
（二）保护表演形象不受歪曲；
（三）许可他人从现场直播和公开传送其现场表演，并获得报酬；
（四）许可他人录音录像，并获得报酬；——首次固定权
（五）许可他人复制、发行、出租录有其表演的录音录像制品，并获得报酬；
（六）许可他人通过信息网络向公众传播其表演，并获得报酬。

（三）表演者的义务（第 38 条）

第三十八条　使用他人作品演出，表演者应当取得著作权人许可，并支付报酬。演出组织者组织演出，由该组织者取得著作权人许可，并支付报酬。
（原第二款并入第 16 条：使用改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品进行演出，应当取得改编、翻译、注释、整理作品的著作权人和原作品的著作权人许可，并支付报酬。）
——双许可双付费

（四）职务表演（第 40 条）

演员为完成本演出单位的演出任务进行的表演为职务表演，演员享有表明身份和保护表演形象不受歪曲的权利，其他权利归属由当事人约定。当事人没有约定或者约定不明确的，职务表演的权利由演出单位享有。
职务表演的权利由演员享有的，演出单位可以在其业务范围内免费使用该表演。

四、录音录像制作者权

（一）概念：录音录像制作者对其制作的录音录像制品，享有许可他人复制、发行、出租、广播（第 45 条，仅限录音制品制作者的获得报酬权）、通过信息网络向公众传播并获得报酬的权利 。

一、概述1.概念：录音录像制作者权简称录制者权，是指录制者对其录音录像制品所享有的权利。
2.录制者权的客体：录音录像制品，包括录音制品和录像制品。（1）录音制品：任何对表演的声音和其他声音的录制品。（2）录像制品：视听作品以外的任何有伴音或者无伴音的连续相关形象、图像的录制品，包括表演形象的原始录制品和非表演形象的原始录制品，后者如自然风光和动物世界的原始录制品。　23
录像制品VS.视听作品：独创性高低。普通的抖音爆火视频，一般为录像制品；但如“东北雨姐”这种博主的视频，其撰稿、拍摄、剪辑等需要大量脑力创意投入，认为其为视听作品也无不可。 3.录制者权的主体：录制者，即录音制品或录像制品的首次制作人。

（二）权利内容（第 44 条、第 45 条）

第四十四条 录音录像制作者对其制作的录音录像制品，享有许可他人复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播并获得报酬的权利；权利的保护期为五十年，截止于该制品首次制作完成后第五十年的 12 月 31 日。

被许可人复制、发行、通过信息网络向公众传播录音录像制品，应当同时取得著作权人、表演者许可，并支付报酬；被许可人出租录音录像制品，还应当取得表演者许可，并支付报酬。

第四十五条（新增加） 将录音制品用于有线或者无线公开传播，或者通过传送声音的技术设备向公众公开播送的，应当向录音制作者支付报酬。（仅支付报酬）

（三）义务（第 42、43 条）

第四十二条 录音录像制作者使用他人作品制作录音录像制品，应当取得著作权人许可，并支付报酬。

录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品，可以不经著作权人许可，但应当按照规定支付报酬；著作权人声明不许使用的不得使用。

第四十三条 录音录像制作者制作录音录像制品，应当同表演者，并支付报酬。

- 避风港原则：

网络上发生著作权侵权案件时，如果网络服务商只提供空间服务，并不制作内容，则网络服务商一旦被权利人告知侵权，就有义务删除相关侵权内容，否则，网络服务商会被视为侵权；如果侵权内容既不在网络服务商的服务器上存储，又没有被权利人告知哪些内容应该删除，则网络服务商不承担侵权责任。这一原则通常也被称之为“通知-删除”规则。

五、广播组织权

（一）概念：是指电台、电视台等广播组织对其编制的广播电视节目依法享有的权利。

（二）权利内容（第 47 条）

第四十七条 广播电台、电视台有权禁止未经其许可的下列行为：

（一）将其播放的广播、电视以有线或者无线方式转播；

（二）将其播放的广播、电视录制以及复制；

（三）将其播放的广播、电视通过信息网络向公众传播。

广播电台、电视台行使前款规定的权利，不得影响、限制或者侵害他人行使著作权或者与著作权有关的权利。

本条第一款规定的权利的保护期为五十年，截止于该广播、电视首次播放后第五十年的 12 月 31 日。

（三）义务（第 46、48 条）

第四十六条 广播电台、电视台播放他人未发表的作品，应当取得著作权人许可，并支付报酬。
广播电台、电视台播放他人已发表的作品，可以不经著作权人许可，但应当按照规定支付报酬。
第四十八条 电视台播放他人的视听作品、录像制品，应当取得视听作品著作权人或者录像制作者许可，并支付报酬；播放他人的录像制品，还应当取得著作权人许可，并支付报酬。

第六节 著作权的利用

一、著作权的转让

二、著作权的许可使用

- 延伸性许可管理

（一）概念、特征及类型

1.独占许可（Sole Licence）：全给一人
2.排他许可（Exclusive Licence）：作者也保留
3.普通许可（Nonexclusive Licence）：给很多人

（二）许可使用合同及其内容

（三）集体许可使用

三、著作权的其他利用

第七节 著作权的限制

一、合理使用

- 知识产权的限制原因：客体的非物质性、利益主体的多元性

（一）合理使用的概念

（二）合理使用的认定

美国：抽象概括式，四要素（不是四个必要的构成要件，只是综合考虑四个要素）

这种使用是否具有商业目的或是为了非营利的教育目的（或者构成转换性使用）；

受版权保护的作品的性质；

同整个有版权作品相比所使用的部分的数量和内容的实质性；

这种使用对有版权作品的潜在市场或价值所产生的影响。

——美国《版权法》107 条的四个要素

大陆法系：公约

本同盟成员国法律得允许在某些特殊情况下复制上述作品，只要这种复制不损害作品的正常使用也不致无故侵害作者的合法利益（对复制权的限制）

——《伯尔尼公约》第 9 条

Step1:只能是在某些特殊情况下使用

Step2:不得与作品的正常利用相冲突

Step3:不得不合理地损害著作权人的合法利益

——《TRIPS 协议》第 13 条的三步检验法

（三）合理使用的范围

- 四要素：

①这种使用是否具有商业目的或是为了非营利的教育目的（或者构成转换性使用）；
②受版权保护的作品的性质；
③同整个有版权作品相比所使用的部分的数量和内容的实质性；
④这种使用对有版权作品的潜在市场或价值所产生的影响。

二、法定许可使用

（一）法定许可使用的概念

作品已发表，依法而不依著作权人许可，向著作权人支付报酬，尊重著作权人其他权利。

- 依著作权人是否可以声明保留，分为相对性法定许可和绝对性法定许可

（二）法定许可适用的范围

（1）报刊转载的法定许可
（2）录音制品制作的法定许可
（3）播放作品和录音制品的法定许可（不包括翻录）
（4）编写出版教科书的法定许可
（5）制作课件的法定许可

（6）扶助农村贫困地区的网络传播法定许可

（三）法定许可使用与合理使用制度之比较

	法定许可使用	合理使用
是否需要同意	无需	无需
是否需要付费	需	无需
法律事实类别	准法律行为	事实行为

三、强制许可使用

强制许可使用，是指在一定条件下，作品的使用者基于某种正当理由需要使用他人已经发表的作品时，经申请由著作权行政管理部门授权，即可使用该作品，无须征得著作权人的同意，但应当向其支付报酬的制度。

四、著作权的穷竭

（一）权利穷竭的含义（Exhaustion of Rights）

又称首次销售原则，是指知识产权人或经其授权的人制造的知识产权产品首次投放市场后，权利人即丧失了在一定地域范围内对该知识产权产品再流通的控制权。凡是合法地取得该知识产权产品的人，均可以对其进行自由处分。其制度宗旨是在保护专利权人合法利益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法利益。

（二）权利穷竭的理论基础

其制度宗旨是在保护知识产权权人合法利益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法利益。其理论基础有：

利益实现说、贸易自由说、利益平衡说等

（三）权利穷竭的地域范围

国内穷竭、地域穷竭（国际穷竭？）

（四）权利穷竭的效力范围

仅限于已经合法投放市场的知识产权产品上的在流通控制权

- 补充：

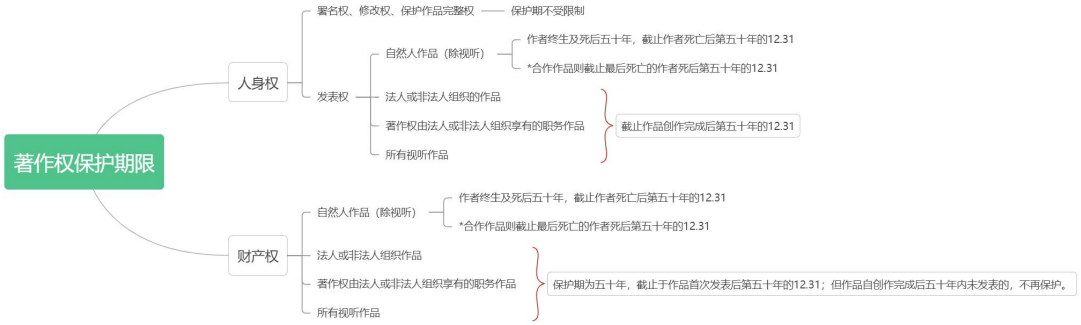
1、取得制度的种类：

A、自动取得制度

B、注册取得制度

C、其他取得制度

2、著作权保护期限



（五）不受著作权保护的情形

1.官方文件

2.单纯事实消息

3.历法、通用数表、通用表格和公式

第二十四条 在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名或者名称、作品名称，并且不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益：

（一）为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品；

（二）为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品；

（三）为报道新闻，在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品；

（四）报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章，但著作权人声明不许刊登、播放的除外；

（五）报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话，但作者声明不许刊登、播放的除外；

（六）为学校课堂教学或者科学研究，翻译、改编、汇编、播放或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行；

（七）国家机关为执行公务在合理范围内使用已经发表的作品；

（八）图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆、文化馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品；

（九）免费表演已经发表的作品，该表演未向公众收取费用，也未向表演者支付报酬，且不以营利为目的；

（十）对设置或者陈列在公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像；

（十一）将中国公民、法人或者其他组织已经发表的以国家通用语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行；

（十二）以阅读障碍者能够感知的无障碍方式向其提供已经发表的作品。

（十三）法律、行政法规规定的其他情形。

前款规定适用于对与著作权有关的权利的限制。

第八节 著作权的保护

（一）认定侵犯著作权的行为（52 条、53 条）、网络侵权认定、侵犯的权利有哪些

1.著作权侵权认定

（1）著作权侵权行为的认定规则：

“实质相似+接触”，即：

第一，两件作品鉴定构成实质相似，即创作之后的作品与创作在先的作品在思想表达形式方面构成同一，前者不具有独创性。

第二，被控侵权作品行为人接触了享有著作权的在先作品，可通过在先作品公之于众来确定或两作品的明显相似来推定。

（2）《著作权法》第 52、53 条规定侵犯著作权的表现形式：

1）未经著作权人许可，发表其作品的；

2）未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的；

3）没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名的；

4）歪曲、篡改他人作品的；

5）剽窃他人作品的；

6）未经著作权人许可，以展览、摄制视听作品的方法使用作品，或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的，本法另有规定的除外；

7）使用他人作品，应当支付报酬而未支付的；

8）未经视听作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人、表演者或者录音录像制作者许可，出租其作品或者录音录像制品的原件或者复制件的，本法另有规定的除外；

9）未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的；

10）未经表演者许可，从现场直播或者公开传送其现场表演，或者录制其表演的；

11）未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的，本法另有规定的除外；

12）出版他人享有专有出版权的图书的；

13）未经表演者许可，复制、发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演的，本法另有规定的除外；

14）未经录音录像制作者许可，复制、发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像制品的，本法另有规定的除外；

15）未经许可，播放、复制或者通过信息网络向公众传播广播、电视的，本法另有规定的除外；

16）未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏技术措施的，故意制造、进口或者向他人提供主要用于避开、破坏技术措施的装置或者部件的，或者故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务的，法律、行政法规另有规定的除外；（区分交互式与非交互式）

17）未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意删除或者改变作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息的，知道或者应当知道作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息未经许可被删除或者改变，仍然向公

众提供的，法律、行政法规另有规定的除外；
18）制作、出售假冒他人署名的作品的

2、网络侵权认定（典型的间接侵权）

网络中的复制权：在有形载体上再现作品；相对持久固定于载体上。

● ？以下情况是否属于该认定范围？

将作品以各种手段固定与芯片、光盘、软件磁盘等媒介上；

将作品上传到网络服务器上；

将作品从网络服务器上或他人的电脑中下载到本地计算机中；

通过网络向他人发送作品（包括手机短信）

点击浏览作品（临时复制）

● 网络中的发行权：向公众提供作品原件或者复制件。？“网络传播”是否构成“发行”？

● 信息网络传播权：

（1）通过网络向公众提供作品、表演、录影录像制品；

（2）传播行为应该是“交互式”传播行为，即公众可以再其选定的时间和地点获得作品、表演或录音录像制品；

● 侵权行为的分类

第一种，直接侵权。行为人未经著作权人许可，又缺乏合理使用、法定许可等抗辩事由，而实施受专有权控制的行为，构成直接侵权。即网络服务提供者自己利用网络，发表侵权作品或信息，侵害他人民事权益。？（购买盗版书是否属于直接侵权？）

第二种，间接侵权。网络服务提供者仅仅提供接入、缓存、信息存储空间。

● “服务器标准”（将作品上传到服务器供公众获得）下的两大类型的网络服务商及其侵权性质认定：

内容服务提供者（ICP)：直接侵权

非内容服务提供者(狭义 ISP)：间接侵权

→“盗链”行为虽为 ISP 提供但也属于直接侵权（盗链是指服务提供商自己不提供服务的内容，通过技术手段绕过其它有利益的最终用户界面(如广告)，直接在自己的网站上向最终用户提供其它服务提供商的服务内容）

● 避风港原则

通知——删除

避风港原则的例外（红旗标准）

第 23 条：网络服务提供者为服务对象提供搜索或者链接服务，在接到权利人的通知书后，根据本条例规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的，不承担赔偿责任；但是，明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的，应当承担共同侵权责任。

第 1196 条：网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

（二）侵犯著作权的法律责任

（三）执行措施

（四）著作权纠纷的调处

（五）著作权的管理

分类：
传统/网络
直接/间接

第四章 专利权

一、专利制度概述

（一）专利与专利权

- 专利：是指经国务院专利行政部门依照法定程序审查认定符合专利条件的发明创造。江苏省×
- 专利权：是指公民、法人或者其他组织对其发明创造在一定期限内依法享有的垄断权。
- 专利法——是调整因发明创造的开发、实施及其保护等发生的各种社会关系的法律规范的总和。

（二）专利法与专利制度

★ 现代专利制度的特点
法律保护
科学审查
公开通报
国际交流

（三）我国专利制度的历史演进

1.我国专利制度的初创期
2.《中华人民共和国专利法》的诞生
3.《专利法》的第一次修改
（1）扩大了专利保护的范围（增加药品、食品、用化学方法获得的物质）
（2）加强了对专利权的保护（增设进口权、用专利方法直接获得的产品受保护）
（3）延长了专利权的保护期限
（4）增加强制许可制度，修改强制许可条件
（5）简化和完善专利审批和维权程序（增设了本国优先权将异议程序改为撤销程序，修改了有关宣告专利权无效的规定）

4.《专利法》的第二次修改
（1）取消对全民所有制企业的“特有”规定；
（2）重新界定了职务发明，明确规定对职务发明人应当给予奖励和报酬；
（3）加大保护力度（增加许诺销售权）；
（4）完善专利司法与行政执法制度（增设诉讼前的临时保护措施，明确赔偿额计算方法，明确地方政府专利管理职能）
（5）简化和完善专利审批和维权程序（取消撤销程序、简化审批流程、增设对实用新型和外观设计专利的复审和无效宣告的司法审查，简化转让和向国外申请专利的手续）
5.《专利法》的第三次修改
（1）修改了新颖性标准（由“混合性标准”改为“绝对新颖性性”）
（2）增加规定了对生物遗传资源的保护（规定了申请人的生物遗传资源“来源披露”义务）
（3）明确了“同一技术方案只能授予一种专利权”原则（即发明和实用新型二者择其一，不能交叉重复）
（4）完善了强制许可制度和合理使用适度（明确滥用专利权强制许可的两种情形、增加规定了为公共健康目的的对专利药品的制造、出口强制许可；增加了一种不视为侵权的行为：为行政审批而实施药品、医疗器械专利）
（5）增加规定了“现有技术的抗辩”（第 62 条）
（6）简化和完善专利审批、维权程序，加大行政执法力度、明确了赔偿数额的计算方法、提高了法定赔偿额，等等
6.《专利法》的第四次修改

二、专利权的客体

（一）专利权客体的种类

第二条　本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
1、发明
（1）发明的概念
发明是指科技开发者依据自然规律或规则，运用自己的资金和智力创造出来的新技术方案。
（2）发明的特点
A.发明是关于自然规律的东西
B.发明是利用自然规律的东西
C.发明是技术领域的创造
（3）发明的分类
● 第一种分类
产品发明：是指以一定的物质形态存在的人工创造出来的新制品。
方法发明：为解决某一技术问题所采取的手段与步骤。

● 第二种分类

首创发明

改进发明

组合发明

应用（用途）发明

选择发明

2、实用新型

（1）实用新型的概念

实用新型——是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

（2）实用新型的特征（与发明相比较）

一是：人工制造的产品

二是：具有一定形状和结构的产品

● 与发明的区别：

①专利种类不同；

②产品的条件有差别，必须具有形状或结构；

③创造性程度不同；

④申请审批的程序不同。

（3）不能申请实用新型专利的情形？

（4）实用新型保护制度的产生与发展

3、外观设计

（1）外观设计的概念

外观设计是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

（2）外观设计的特征或构成要素

产品要素：必须与产品结合

设计要素：形状、图案、色彩或其结合

美感要素：有差别，能引人注意

工业应用要素：能批量生产

（3）与发明和实用新型的区别？

（4）制度存在的原因及其产生与发展？

（二）授予专利的条件（可专利性）

1、可专利性的概念

第 22 条第 2 款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

2、发明和实用新型的可专利性

（1）新颖性

● 现有技术及其判定的标准：

第 22 条第 5 款：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”

（1）时间标准：申请日或优先日

（2）公开标准：公开的对象、方式、程度

（3）地域标准：国内外

（4）判断原则：单独对比原则（在判断申请专利的发明或实用新型是否具有新颖性时，专利审查人员只能将每一份对比文件作为一个整体单独与被审查对象进行比较，而不允许将几份对比文件组合起来作为判断该申请是否具有新颖性的标准）

● 冲突（抵触）申请：

（1）概念——在先申请、在后公布的申请

（2）构成条件：

A、申请在先

B、先后两申请的申请人不同

C、先后两申请具有相同的技术主题

D、在先申请尚未公开，但仍是有效申请

（3）法律效力：使在后申请丧失新颖性

丧失新颖性的例外（宽限期）

第 24 条：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开（加）；

（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

【思考题】

1、如果他人在宽限期内就相同的主题在先提出申请，则谁的申请有效？

2、如果他人在宽限期内公开同样的主题，能否使申请人的发明创造丧失新颖性？

3、如果发明人、设计人或其他有关人员在宽限期内又以出版物方式公开，则是否丧失新颖性？

4、如果他人在宽限期内使用了该项发明创造，是否构成侵权？

（2）创造性

创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

● 创造性判断的原则和方法：

对比的对象：“已有的技术”

对比的文件：采用组合对比原则

评价者：所属领域的技术人员（虚拟人）

评价的方法：

A、确定最接近的现有技术；

B、确定发明的区别特征和其实际解决的技术问题；

C、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

(3)实用性

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

● 判断原则：

A、以申请日前提交的说明书和权利要求书所公开的整体技术内容为依据；

B、以所属领域技术人员能够实施为标准；

C、与技术如何创造出来和是否已经实施无关。

● 不具有实用性的几种情形：

①不具有再现性；

②违背自然规律；

③利用独一无二的自然条件的产品；

④人体或者动物的非治疗目的的外科手术方法；
⑤没有积极效果；
⑥测量人体在极限情况下的生理参数的方法。

3、外观设计的可专利性

第二十三条 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

- 外观设计的新颖性的标准：

（1）对象为产品的外观：包括产品的形状、图案、色彩及其结合
（2）公开的方式：出版物和使用公开
（3）不相同和不相近似的产品（分类标准是产品的用途）
（4）不相同和不相近似的外观
（5）判断的主体：一般消费者

（四）不授予专利的对象

1、违反善良风尚的发明创造

第五条：对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成发明创造，不授予专利权。

2、不可获得专利的主题

第 25 条：对下列各项，不授予专利权

（一）科学发现；
（二）智力活动的规则和方法；
（三）疾病的诊断和治疗方法；
（四）动物和植物品种；
（五）原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质；
（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合做出的主要起标识作用的设计

【思考题】

下列内容哪些可以获得发明专利权？哪些可以获得实用新型专利权？哪些可以获得外观设计专利权？那些不可以获得专利权？

A、制造新药的工艺（发明）
B、可有效降低风阻力系数的汽车车身造型（实用新型）
C、优美的童车造型（外观设计）
D、一种饮料的新配方（发明）
E、一种专门用于赌博作弊的透明麻将牌（×）
F、一种化学合成的新材料（发明）
G、手工制作的造型独特的花瓶（×）
H、用一种全新的材料取代现有材料做成的水杯（发明）

三、专利权的主体及权利归属

（二）发明人或设计人

1、发明人或者设计人的概念：

《实施细则》第 13 条： 专利法所称的发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

2、发明人或者设计人的权利：

（1）在专利申请文件中署名的权利（第 17 条第 1 款）

（2）在非职务发明中取得专利申请权和专利权（第 6 条）

（3）在职务发明中获得奖励和报酬的权利（第 16 条、《细则》第六章第 76-78 条）

（三）专利申请权（专利权）及其归属

1、专利申请权的概念和特征

- 概念：专利申请权是专利申请人依据法律规定或合同约定享有的就发明创造向国务院专利行政部门提出专利申请的权利。
- 特征：相对性、暂时性、相关性

2、专利申请权的归属——专利申请人

（1）原始取得（第 6 条）

第六条 ：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用（增加）。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

A、职务发明：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

《实施细则》第十二条： 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：

（一）在本职工作中作出的发明创造；

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

（三）退职、退休或者调动工作后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

B、非职务发明

（2）继受取得（第 10 条）

第十条：专利申请权和专利权可以转让。

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权

的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理。

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

3、专利申请权人的权利

- 对抗在后申请的权利
- 要求优先权的权利
- 取得临时保护的权利
- 转让专利申请权的权利
- 在专利申请中享有的撤回权、修改权、修改请求权、陈述意见权、实质审查请求权、放弃权等

（四）专利申请权的权利内容

四、专利权的取得

（一）专利申请原则

1、书面原则（细则第 2 条）

2、先申请原则 （第 9 条）

第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

3、优先权原则（第 29 条）

4、单一性原则 （第 31 条）

第三十一条： 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出。

（二）专利申请日与优先权

1、专利申请日（第 28 条）

第二十八条：国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

2、优先日（细则第 11 条）

- 优先日与申请日：

《实施细则》第十一条：除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请

日，有优先权的，指优先权日。
本细则所称申请日，除另有规定的外，是指专利法第二十八条规定的申请日。

- 国际优先权（第 29 条第 1 款）

第 29 条第 1 款：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

- 国内优先权（第 29 条第 2 款）

第 29 条第 2 款：申请人就其发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请后 12 个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内（加），又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

- 优先权的行使方式（第 30 条）

第三十条：

申请人要求发明、实用新型优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在第一次提出申请之日起十六个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；

申请人要求外观设计专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；

未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权。

（三）专利申请文件

1、发明或者实用新型申请文件
请求书
说明书 及摘要
权利要求书 （格式）
2、外观设计申请文件
请求书
图片或照片

（四）中国单位、个人向国外申请专利

1、向外国申请专利的方式
向有关国家或者地区提出专利申请
向 PCT 国际局提交国际申请
2、向外国申请专利的注意事项
国内完成，国外申请
国外完成，国外申请
涉及微生物的国际专利申请的进出口许可证和微生物保藏问题

第二十条 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。（修改）

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。

国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。

对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。（增加）

（五）专利申请的审批

1、审查制度的历史发展

2、发明专利申请的审批

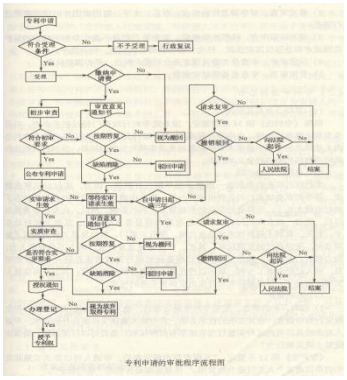
- 初步审查 （形式审查）
- 公布申请（第 34 条）

第三十四条：国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

- 实质审查（第 35 条）

第三十五条：发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。

国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。



专利申请的审批程序流程图

3、实用新型或者外观设计专利申请的审批

第四十条：实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

4、权利的丧失与恢复（法条）

实施细则第 7 条第 1 款：当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起 2 个月内，最迟自期限届满之日起 2 年内，可以向国务院专利行政部门说明理由并附具有关证明文件，请求恢复权利。

实施细则第 7 条第 2 款：当事人因正当理由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起 2 个月内向国务院专利行政部门说明理由，请求恢复权利。

五、专利权的期限、终止与无效

（一）专利权的期限

第 42 条：发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年（改），均自申请日起计算。

自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外（20 年新增）

为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年（20 年新增）

（二）专利权的终止

第 44 条：有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：

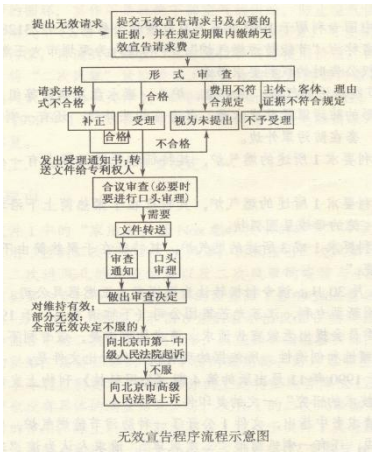
（一）没有按照规定缴纳年费的；

（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。

专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

（三）专利权的无效宣告

第 45 条：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门（2019 年机构改革，原为“国家知识产权局专利复审委员会”，现为“国家知识产权局专利局复审和无效审理部”）宣告该专利权无效。



无效宣告程序流程示意图

六、专利权的内容、限制与特别许可

（一）专利权的内容

（1）独占实施权

第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

专利实施许可的种类：

- 独占许可
- 独家（排他）许可
- 普通许可
- 分许可（再许可）
- 交叉许可
- 专利池许可

（2）转让权

（3）实施许可权

（4）放弃权

（5）标记权

（6）出质权

（二）专利权的限制

1. 强制许可

（1）防止专利权滥用的强制许可

第 53 条：有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：

（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；

（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

（2）为公共利益目的的强制许可

第 54 条：在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

（3）交叉强制许可（案例分析）

第 56 条：一项取得专利权的发明或者实用新型比此前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

（4）药品专利的强制许可

第 55 条：为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。（增加）

- （补充）当地实施强制许可

专利当地实施要求是指专利权人必须在授予其专利的国家充分实施其专利，否则东道国可以强制许可实施甚至撤消该专利的限制制度。

2. 不视为侵犯专利权的行为

A、专利权的穷竭

B、先用权人的实施

C、临时过境使用

D、为科学研究和实验而使用

E、为医药行政审批的使用（Bolar 例外）

第 75 条： 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。

（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者医疗器械的。

3.国家指定许可

第 49 条（原第 14 条）：国有企业事业单位的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。

（三）专利权的开放许可

专利权人自愿提交专利开放许可声明，对专利许可使用费“明码标价”，由国务院专利行政部门向全社会“广而告之”，任何单位或个人书面通知专利权人并按照标价付费即可获得实施许可，对所有被许可方“一视同仁”。

（四）标准必要专利许可（FRAND 原则（公平、合理和无歧视））首案：华为 v.IDC

在使用国际标准、国家标准或行业标准时，必须使用的专利许可。如果一个技术标准得到了广泛应用而成为行业标准或者国家强制性标准，达不到标准的产品或者服务就不能进入

市场，这个技术标准对相关企业就是强制性的要求。在这种情况下，因为标准的开放性，与标准必要专利相关的技术许可就具有公共性，涉及社会公共利益。

华为技术有限公司与 IDC 公司滥用市场支配地位纠纷上诉案

【案号】

一审：（2011）深中法知民初字第 858 号；

二审：（2013）粤高法民三终字第 306 号

【基本案情】

原告：华为技术有限公司。

被告：交互数字技术公司(InterDigital Technology Corporation)。

被告：交互数字通信有限公司(InterDigital Communications，Inc)。

被告：交互数字公司(InterDigital，Inc)。

本案与华为公司诉交互数字技术公司等四被告标准必要专利使用费率案【一审：（2011）深中法知民初字第 857 号二审：（2013）粤高法民三终字第 305 号】为系列案件。

在本案中原告诉称，根据我国反垄断法的规定，被告在 3G 无线通信标准必要专利许可市场中具有市场支配地位。与苹果、三星等公司相比，被告对其标准必要专利的许可使用费存在过高定价和歧视性定价行为；被告还要求原告将原告全球所有的专利无偿许可给被告，这属于附加不合理交易条件的行为；被告提出将其标准必要专利和非标准必要专利、2G、3G 和 4G 标准必要专利、全球专利打包许可，这属于搭售行为；在双方谈判过程中，被告突然在美国联邦法院和美国国际贸易委员会同时起诉原告，本质上是拒绝与原告进行交易的行为。据此，原告诉请三被告立即停止过高定价、差别定价、搭售、附加不合理交易条件以及拒绝交易等垄断民事侵权行为，并连带赔偿原告经济损失人民币 2000 万元。

【裁判要旨】在无线通信技术标准中，每一个标准必要专利许可市场，均构成一个独立的相关商品市场；专利权具有地域性，每一个主权国家中的标准必要专利许可市场又是一个独立的相关地域市场。基于标准中每一个标准必要专利的唯一性和不可替代性，标准必要专利权人在相关市场中具有市场支配地位。如标准必要专利权人在标准必要专利使用费谈判中，违反公平、合理、无歧视的原则，比如，实施过高定价、歧视性定价、搭售等滥用市场支配地位的行为，将被认定为构成垄断，应承担相应的民事侵权法律责任。

七、专利权的保护

（一）专利权的保护范围

1、发明或者实用新型专利权的保护范围

（1）确定的依据：

第 64 条 第 1 款：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

（2）三种学说：

- 周边限定论：指专利权的保护范围完全按照权利要求书的文字确定，对文字作严格、忠实的解释，文字表达的范围就是专利权保护的最大范围。
- 中心限定论：指权利要求的文字表达的范围仅仅是专利权保护的最小范围，可以以权利要求书记载的技术方案为中心，通过说明书及其附图的内容全面理解发明创造的整体构思，将保护范围扩大到四周的一定范围。

- 折中解释论：是指专利权的保护范围应根据权利要求所表示的实质内容加以确定，在对权利要求所表示的技术特征存在疑义时，可以引用说明书和附图进行解释。

2、外观设计专利权的保护的保护范围

第 64 条第 2 款：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

（二）专利侵权及其认定

1、直接侵权行为

（1）直接侵权的概念：所谓专利（直接）侵权，是指行为人在专利权有效期内，在未经专利权人的许可，又无法律根据的情况下，为经营目的擅自实施他人专利的行为。

第 65 条：未经专利权人许可，实施其专利的，即侵犯其专利权，……

第 11 条：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

（2）直接侵权的构成

- 有效专利的存在
- 有实施他人专利的行为
- 实施专利的行为具有不法性
- 以生产经营为目的

（3）直接侵权的判定

- 专利有效原则
- 折中原则
- 技术特征完整对待原则
- 全面覆盖（相同）原则（司解）

2009《司解》第七条：

人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

- 等同原则　　（司法解释）

2001 年《司法解释》：

第十七条 ：专利法第五十六条第一款所称的"发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求"，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

- 禁止反悔原则　（案例）（司解）

2009 年《司解》第六条：

专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修

改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

- 多余指定原则 （案例）
- 公知技术的抗辩（法条）

第六十七条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。（增加）

2009《司解》第十四条：

被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二（修改后即67条）条规定的现有技术。

被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

2、间接侵权行为

（1）概念：行为人自己没有进行直接侵犯专利权的行为，但是却故意诱导、怂恿、唆使他人实施他人的专利或者对直接侵权行为的发生起到了帮助作用的行为。

（2）种类：“诱导侵权”与“帮助侵权”

（3）构成要件

A、以直接侵权行为的发生为前提

B、主观上存在侵权故意

C、客观上实施了诱导、帮助侵权的行为

D、间接侵权的对象是“没有实质性非侵权用途”的产品

（4）主要表现

第一，销售构成专利产品的核心零部件，或专门用于实施专利产品的磨具，或者用于实施专利方法的机器设备；

第二，未经专利权人授权擅自许可或委托他人实施专利。

3、假冒他人专利

A.假冒他人专利的定义:非专利权人未经专利权人的许可，在其产品投入流通过程中使用他人的专利号或伪造、变造他人专利证书、专利文件 、专利申请文件的行为。

B.假冒他人专利的种类

细则第八十四条：下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：

（一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；

（二）销售第（一）项所述产品；

（三）在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；

（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

（五）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。

专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。

销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。

C.假冒他人专利的构成

- 必须实施了假冒行为
- 假冒的对象是他人有效的专利
- 假冒专利的行为是故意行为

D. 假冒他人专利的法律责任

第 68 条 假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元一下的，可以处二十五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

药品链接制度

（三）专利纠纷及其处理

1、管理部门对专利侵权纠纷的调处

2、人民法院对专利侵权纠纷的审理

第六十五条 未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

（四）专利侵权的法律责任

1.法律责任的类型

2.赔偿数额的确定

3.惩罚性赔偿

4.责任免除

第 71 条：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

第五章 商标法

一、商标与商标权

（一）商标概述

1、商标的概念

商标的定义：是生产经营者在其商品或服务上使用的，具有显著性、便于识别商品或服务来源的标志（注意：商标不等于标志本身）。

《商标法》第 8 条： 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的（删除了“可视性”）标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

2、商标的特征（与相邻标志的区别）

（1）商标与商品名称

（2）商标与商号

一般而言，商标必须与其所依附的特定商品相联系而存在，而商号则必须与生产或经营该商品的特定厂商相联系而存在。

	商号	商标
对象不同	市场主体（1 个/没有）	商品或服务来源的标志
使用要求不同	不经登记不得使用	自愿原则（是否需要取得专用权-登记）
登记注册的法律效力不同	专用权仅限于登记主管机关所辖范围	全国

（3）商标与地理标志

地理标志是标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或其他特征，主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。地理标志可以作为证明商标或者集体商标申请注册。

	地理标志	商标
功能	表明商品产地、质量和特有品质，有品质担保、质量认证的功能	指示商品的生产经营者，并不直接反映商品质量和特色
权利主体	不宜独占，可以作为集体商标或证明商标，该地区某一商品或服务的经营者共同使用	由独立的民事主体申请注册取得专用权，并可排除任何第三人的注册和使用

（4）商标与特殊标志

（5）商标与商品装潢

	商品装潢	商标
使用目的	说明、美化、刺激购买	区别不同的经营者
构成要素	不限	选材不得与商品内容相同
使用要求	不限	由法律直接予以规范

3、商标的分类

（1）味觉商标

定义：通过味觉进行识别的商标。由于味道是食品或饮料等本身的特点，通常不被消费者认为是在识别特定的出处，但至少从理论上不能绝对排除味道经过长期使用可能获得的显著性。

例如：孩之宝（Hasbro, Inc.）于 2017 年将培乐多彩泥特有的气味通过美国专利商标局（USPTO）申请气味商标，并获得成功注册。这股复杂的气味被描述为“一种甜味、略带麝香味及香草味的混合，同时略带樱桃味，以及咸味小麦面团的自然气味”。

（2）视觉商标

①立体商标：以长、宽、高三维的标志为构成要素的商标，以及由含有其他标志的三维标志构成的商标。立体商标可以是商品本身的形状、商品的包装物或者其他三维标志。

②平面商标

A. 文字商标

B. 图形商标

C. 颜色组合商标

D. 组合商标

（3）听觉商标

定义：是指由声音构成、通过听觉识别的商标，包括音乐性的和非音乐性的自然界的声音、人或者动物的声音，以及多种声音的结合。

从 2014 年 5 月 1 日新商标法施行，商标局开始受理注册声音商标的申请，出台了《声音商标形式和实质审查标准（试行）》

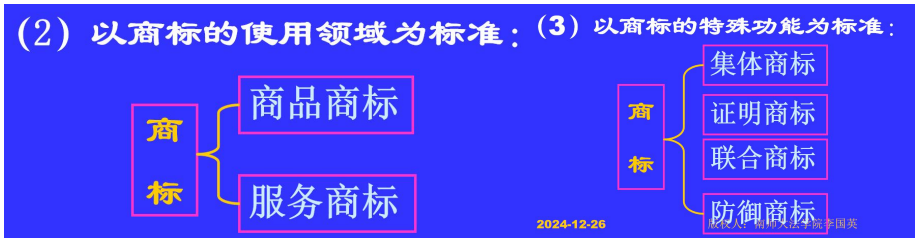
例：“声音商标 小喇叭”，“嗒嘀嗒，嗒嘀嗒，嗒嘀嗒嗒嗒……小喇叭开始广播了……”，这是中央人民广播电台《小喇叭》节目的开播音乐，2014 年 9 月 28 日申请注册，申请使用于第 38 类和第 41 类服务上，2016 年 12 月 6 日初审公告，2017 年 3 月 7 日核准注册。《小喇叭》儿童节目开播于 1956 年 9 月 4 日，伴随了近三代人的成长，其显著性是不言而喻的。

【案例 1】QQ 提示音商标案

腾讯 QQ 聊天的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（共 6 声），2015 年被驳回，理由是“该声音较为简单，缺乏独创性，难以起到区分服务来源的作用”。腾讯申请复审，2016 年 4 月 18 日，商标评审委员依然做出了驳回的复审决定。腾讯向北京知识产权法院提出了行政诉讼，2018 年 4 月，法院一审判决支持腾讯的诉讼请求，撤销了商标局商标评审委员会作出的决定。商评委不服上诉，2019 年 12 月 14 日，北京高院二审维持。

【案例 2】李佳琪声音商标案

“Oh my god，买它买它！”该商标申请注册号为 45217353，申请日期为 2020 年 4 月 7 日，用在第 35 类“替他人推销”等服务上，该商标摘要显示，该商标是以成年男子的人声念出。语速较快，声调较高（因没有显著性被商标局驳回）。



- 集体商标：以团体、协会、其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。
- 证明商标：对某种商品或服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者

个人使用于其商品或服务，用于证明该商品或服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

- 联合商标：同一商标所有人在同一种商品或类似商品上注册使用的若干个近似于其主商标的商标。首先注册的为主商标，其他商标为该商标的联合商标。例如：“娃哈哈”为主商标，“哈哈娃”、“娃娃哈”等为联合商标。

✧ 功能：保护主商标、储存商标、节约维权成本

✧ 转让限制：应当一并转让

第 42 条第二款：转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

- 防御商标是指驰名商标所有人在非类似商品或服务上分别注册的若干相同的商标。原来注册的商标为主商标，在其他类别的商品或服务上注册的同一商标为防御商标。

✧ 功能：保护主商标、储备商标、节约维权成本

4、商标的功能

（1）识别商品或服务的来源

（2）标示或监督商品或服务的质量

（3）指导商品的选购或服务的选择

（4）便于商品或服务的广告宣传

（二）商标制度的产生与发展

（三）商标权的概念与内容

1、概念：商标权是商标所有人依法对其注册商标所享有的权利。

2、内容：

（1）专有使用权：由法律授予商标权人在指定商品或服务上使用其注册商标的排他性权利。

（2）禁止权：注册商标权人有权禁止他人未经许可在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。

（四）商标权的取得及终止

1、商标权的取得

原始取得：

注册取得（基本方式）

使用取得（美国为代表）

混合取得（德国为代表）

继受取得：转让、继承、企业兼并等

2、商标权的消灭

（1）注销

主动申请注销

过期注销

无人继承注销

（2）撤销（《商标法》第 49 条）

使用不当撤销

丧失显著性撤销

三年不使用撤销（“撤三”）

（3）无效

第 49 条第 1 款：商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

第 49 条第 2 款：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

二、商标注册

（一）商标注册的原则

1. 自愿注册原则（第 6 条）

第六条：法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。

强制注册的规定：《烟草专卖法（2015）》第 19 条规定：卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册，未经核准注册的，不得生产、销售。

2. 先申请原则（第 31 条）

第 31 条第 1 款:两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；

第 31 条第 2 款:同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

3. 优先权原则（第 25、26 条）

第 25 条（第 1 款）：商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者按照相互承认优先权的原则，可以享有优先权 。

第 26 条（第 1 款）：商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的，自该商品展出之日起六个月内，该商标的注册申请人可以享有优先权。

4. 分类注册与一标多类原则（第 22 条）

第 22 条第 1 款：商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请。

第 22 条第 2 款：商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标

（二）商标注册的条件

1.商标注册的积极条件

（1）商标构成要素的法定性

《商标法》第 8 条：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册”。

（2）商标标志的显著性：商标应当具备的足以使相关公众区分商品或服务来源的特征。

《商标法》第 9 条第 1 款：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。

- 商标显著性的类型：

①固有显著性：一个标志由于正确选用而具有天生的标示产品出处并区别于他人产品的属性。

✧ 臆造商标、任意商标、暗示商标

②获得显著性：一个缺乏固有显著性的标志通过长期连续使用而产生新的含义，具备识别商品的能力时，该标志即被视为具备了显著性特征。

Eg.“百度”

✧ 描述性商标、其他无显著性商标

显著性的丧失：商标变成通用名（“优盘”案）

- 显著性的认定原则：结合相关公众认定原则、结合商品或服务具体认定原则、整体认定原则与考虑公共利益的原则

（3）注册目的的正当性

第 4 条第 1 款：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回（新增加）。

- 要件：没有使用意图+恶意

2.商标注册的消极条件

（1）商标标志的非禁用性

标志：第 10 条第 1 款 1-5 项

地名商标：第 10 条第 2 款

民族歧视性商标：第 10 条第 1 款 6 项

欺骗性商标：第 10 条第 1 款 7 项

不良影响商标：第 10 条第 1 款 8 项

第十条　下列标志不得作为商标使用：

（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；

（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

（六）带有民族歧视性的；

（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其

他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

（2）商标标志的非侵权性

第 9 条：不得与他人在先取得的合法权利相冲突；

第 32 条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

- 在先权利：包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。

（3）商标标志的非功能性

第十二条：以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。

- 三维标志的技术功能和美学功能：

三维标志仅由商品自身性质产生的立体形状组成（如“手电筒”形状商标）

三维标志仅由为获得技术效果而需有的商品立体形状组成（如飞利浦三头“剃须刀”商标，原为发明专利）

三维标志仅由使商品具有实质性价值的立体形状组成（六个褶“苹果馅饼”商标）

（4）商标标志的非冲突性

《商标法》第 30 条：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《商标法》第 13 条第 2、3 款：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用；就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

（三）商标注册的申请

1.申请人：任何民事主体

2.申请文件：申请书、商标图样和证明文件（《条例》第 13 条）

《条例》第 13 条第 1 款：申请商标注册，应当按照公布的商品和服务分类表填报。每一件商标注册申请应当向商标局提交《商标注册申请书》1 份、商标图样 1 份；以颜色组合或者着色图样申请商标注册的，应当提交着色图样，并提交黑白稿 1 份；不指定颜色的，应当提交黑白图样。

《条例》第 13 条第 2 款：商标图样应当清晰，便于粘贴，用光洁耐用的纸张印制或者用照片代替，长和宽应当不大于 10 厘米，不小于 5 厘米。

3. 另行注册、重新注册、变更注册、转让和转移注册（法条）

第 23 条：注册商标需要在核定使用范围之外的商品上使用的，应当另行提出注册申请。

第 24 条：注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。

第 41 条：注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出变更申请。

《条例》第 31 条：转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。

《条例》第 32 条：注册商标专用权因转让以外的继承等其他事由发生移转的，接受该注册商标专用权的当事人应当凭有关证明文件或者法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。

4. 特殊商标的注册申请

《实施条例》第十三条：对三位标志、颜色组合、声音标志、集体商标、证明商标和外文商标的注册申请提出了特别的要求。

《实施条例》第四十三条："指定中国的领土延伸申请人，要求将三维标志、颜色组合、声音标志作为商标保护或者要求保护集体商标、证明商标的，自该商标在国际局国际注册簿登记之日起 3 个月内，应当通过依法设立的商标代理机构，向商标局提交本条例第十三条规定的相关材料。未在上述期限内提交相关材料的，商标局驳回该领土延伸申请。"

《条例》第 13 条第 3-7 款：

以三维标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式，并提交能够确定三维形状的图样，提交的商标图样应当至少包含三面视图。

以颜色组合申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式。

以声音标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，提交符合要求的声音样本，对申请注册的声音商标进行描述，说明商标的使用方式。对声音商标进行描述，应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；无法以五线谱或者简谱描述的，应当以文字加以描述；商标描述与声音样本应当一致。

申请注册集体商标、证明商标的，应当在申请书中予以声明，并提交主体资格证明文件和使用管理规则。

商标为外文或者包含外文的，应当说明含义。

（四）商标注册的审查与核准

1、形式审查：商标申请的文件是否齐备、填写是否符合要求

（1）申请日的确定

（2）申请的补正

（3）申请的退回

第 33 条：对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

2、实质审查：商标标志是否符合注册条件

（1）是否为使用善意注册

（2）是否可感知

（3）是否具有识别性

（4）是否违反公序良俗

3、公告与异议

4、核准注册

5、商标评审：行政机关对商标争议事宜再次审查的制度

（五）商标注册的无效

1.无效宣告的启动

（1）商标局主动宣告无效

（2）第三人申请商标局宣告无效

2.商标无效的事由：违反禁止性规定、以不当手段取得注册、其他不正当注册的行为

（1）不得自注册的绝对事由（第 44 条）

第 44 条第 1 款：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会（注：该机构已撤并，现为商标局内部评审结构）宣告该注册商标无效。

（2）不得自注册的绝对事由（第 45 条）

第 45 条第 1 款：已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会（注：该机构已撤并，现为商标局内部评审结构）宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

3.无效宣告的效力

第四十七条　依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

- 补充：商标权的撤销

第四十九条　商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

第五十五条　法定期限届满，当事人对商标局做出的撤销注册商标的决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的，撤销注册商标的决定、复审决定生效。

被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。

三、商标评审

（一）商标评审的含义

（二）商标评审的机构

（三）商标评审的类型



（四）商标评审的效力（司法审查）

四、商标权的行使

（一）商标权的续展

1、续展的概念和法律规定（第 40 条）

第四十条　注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册

商标。

商标局应当对续展注册的商标予以公告。

2、续展的程序

3、续展期间的临时保护

4、续展的性质

（二）商标权的转让

1、商标权转让的概念

2、商标权转让的原则（连同转让 or 自由转让）

3、商标权转让的形式与程序

4、商标权转让的限制（第 42 条）

第四十二条　转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。

转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

（三）商标权的使用许可

1、使用许可的概念

2、使用许可的种类

3、被许可人的诉讼地位

4、使用许可合同的内容

5、使用许可合同的备案程序（第 43 条）

（四）商标权的其他行使方式

五、商标管理

（一）商标管理概述

（二）商标使用管理（商标法第六章）

（三）商标印制管理

（四）企业内部商标管理

（五）对外贸易的商标管理

六、商标权的保护

（一）商标权保护概述

（二）商标侵权行为的种类

第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的（反向假冒）；

（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

（三）商标侵权的认定标准

1.侵权认定的标准——混淆的可能性

售前混淆（适用《反法》）

售中混淆（“混淆的可能性”标准适用范围）
售后混淆（“知假买假”商标侵权）
反向混淆（课后自学“新百伦”案）

2. “混淆的可能性”认定：近似商标与类似商品

- 商标近似：商标标志的外观、发音、字意相似，容易使人发生混同。
- 商标类似：在功能、用途、原料、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆的商品。（比如冰柜与冰箱）

第十条 人民法院依据商标法第五十七条第（一）（二）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：

（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十一条 商标法第五十七条第（二）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。

2014《实施条例》第 75 条：

为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等，属于商标法第五十七条第六项规定的提供便利条件。

2020 年《司法解释》：

第一条 下列行为属于商标法第五十七条第（七）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

- 商标的“淡化”：对著名商标识别其商品或服务的能力的削弱，而无需考虑商标所有人和他人是否存在竞争关系，或是否会在商品之间引起混淆、误认或欺骗。

（四）商标侵权行为的法律责任

1、商标侵权案件的处理机关：

（1）市场监督管理机关

（2）人民法院

2、法律责任：

（1）民事责任

（2）行政责任
（3）刑事责任

七、驰名商标的特别保护

（一）驰名商标概述

1、驰名商标的含义

《规定》第 2 条：驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

2、认定的标准（商标法第 14 条）

第 14 条　认定驰名商标应当考虑下列因素：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标驰名的其他因素。

（二）国际公约的特别保护

1、《巴黎公约》的规定

（第六条之二）

（一）商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标，已经成为有权享有本公约利益的人所有，而另一商标构成对此驰名商标的复制、仿造或翻译，用于相同或类似商品上，易于造成混乱时，本同盟各国应依职权——如本国法律允许——或应有关当事人的请求，拒绝或取消该另一商标的注册，并禁止使用。商标的主要部分抄袭驰名商标或是导致造成混乱的仿造者，也应适用本条规定。

（二）自注册之日起至少五年内，应允许提出取消这种商标的要求。允许提出禁止使用的期限，可由本同盟各成员国规定。

（三）对于以不诚实手段取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的要求的，不应规定时间限制。

2、《TRIPS 协定》的规定

（第 16 条）

2.巴黎公约 1967 年文本第六条之 2，原则上适用于服务。确认某商标是否系驰名商标，应顾及有关公众对其知晓程度，包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。

3.巴黎公约 1967 年文本第六条之 2，原则上适用于与注册商标所标示的商品或服务不类似的商品或服务，只要一旦在不类似的商品或服务上使用该商标，即会暗示该商品或服务与注册商标。所有人存在某种联系，从而注册商标所有人的利益可能因此受损。

（三）我国的驰名商标保护制度

1、2014《驰名商标认定和保护规定》

2、驰名商标认定的认定方式与机构

（1）认定的原则

“个案认定，被动保护”(法条)

第 13 条第 1 款：为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

（2）认定的机构（第 14 条第 2、3、4 款）

国家知识产权局

人民法院的认定

第 14 条第 1 款：驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。

《规定》第 4 条：驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则。

第 14 条第 2、3、4 款：

在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

在商标争议处理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标评审委员会根据处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

（3）认定的法律效力（第 14 条第 5 款）

第 14 条第 5 款：

生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

3、驰名商标的认定程序

（1）商标注册过程中的认定

（2）商标使用过程中的认定

（3）商标民事纠纷案件处理过程中的认定（司法解释）

应该认定的情形：

第二条 在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：

（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；

（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；

（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。

不予认定的情形：

第三条 在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：

（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（如“谷歌”案）

（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。

原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认为由，提起的侵权诉讼，按照前款第（一）项的规定处理。

不需要认定驰名商标时不得认定：

【案例】

原告谷歌（Google）信息技术（中国）有限公司诉被告北京谷歌科技有限公司商标侵权及不正当竞争案。被告将“谷歌”翻译名称恶意注册为企业名称而引发纠纷。一审判决被告停止使用企业名称，并向工商行政管理机关申请变更企业名称。变更后的企业名称不得包含“谷歌”字样，并赔偿原告经济损失及合理支出 10 万元。二审法院维持了原判，但认为此案不涉及商标的跨类保护或者其他认定驰名商标的情形，并对此予以纠正。——（2008 年）海民初字第 7567 号；（2009 年）一中民终字第 4477 号。

4、我国对驰名商标的特别保护

（1）未注册受保护（第 13 条第 2 款）

（2）跨类保护（第 13 条第 3 款）

（3）豁免撤销权的除斥期间

第 45 条：已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

《商标法》第 13 条第 2、3 款：

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。 （司法解释）

2009 驰名商标《司法解释》第九条 ：

足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，属于商标法第十三条第一款规定的“容易导致混淆”。

足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱（blur）驰名商标的显著性、贬损（tarnish ）驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

- 驰名商标反淡化与商标侵权的区别：

1、适用范围限于著名的商标(famous trademark)，反淡化保护的目的是商标的显著性和联系的唯一性。

2、不构成来源混淆，即商标侵权难以保护（Professor McCarthy's "one mark: two sources" blurring rationale.）

associate the disputed mark with the plaintiff, and

not be confused into thinking that the plaintiff is the source or sponsor of the challenged goods.“（典型案例）

八、补充：商标权的限制问题

（一）何为商标权限制？

（二）商标权该不该限制？

（三）学界的商标权有哪些限制？

1、商业使用

（1）正当使用

A、描述性使用

B、指示性使用

（2）在先使用

（3）权利用尽

（4）比较广告（“七喜不是可乐”、诺基亚和微软在广告中讽刺苹果 Ipad 没有 USB 接口 ）

2、非商业使用（言论自由）（反淡化的例外）

（1）新闻报道与评论

（2）滑稽模仿

（3）字典等参考书中使用

（四）我国商标法上的不侵权规定

1.正当使用（法条）

A、描述性使用（案例）

B、指示性使用（概念与构成）

第 59 条第 1 款： 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

第 59 条第 1 款：三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

- 正当使用的认定要件

第 59 条第 3 款 ：

商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

- 指示性使用：就是被告用原告的商标来指称原告的产品而不是来描述被告自己的产品。
- 三个要件：

A、被告如果不使用原告的商标就难以简明扼要地辨识其产品；

B、被告使用原告的商标仅限于辨识原告的产品；

C、被告不能以任何方式明示或暗示原告支持或授权使用其商标。

- 典型案件（花花伴娘案）
- 美国《联邦商标反淡化法》(FTDA)规定了三种例外：

（1）在广告或促销中对注册商标合理使用

（2）对商标的非商业性使用

例如：滑稽模仿（parody)

（3）各种形式的新闻报道和新闻评论

2.在先使用（法条）